

1501154-59.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Eis a ementa: Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prova ilícita. Guarda municipal. Competência constitucio- nal. Atividade policial. A atividade de policiamento urbano, seja para repressão dos crimes, seja para sua investigação, é daquelas de maior complexidade que o Estado presta a sua população. Reclama, pois, seleção rigorosa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501154-59.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000991

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2207979/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANIEL CESAR SANJUAN CLAZER

Réu Preso

Aos 12 de dezembro de 2022, às 14:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. ANTONIO CARLOS PEREZ ANTUNES DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: DANIEL CESAR SANJUAN CLAZER - PRESENTE (via videoconferência)

Defensora constituída: Dra. OLGA MARIA VECCHINI PELAES - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC CESAR EDUARDO BOTTENE - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JUVENAL ESTEVÃO DE MACEDO - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha GC CESAR EDUARDO BOTTENE.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC JUVENAL ESTEVÃO DE MACEDO, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC JUVENAL ESTEVÃO DE MACEDO, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu DANIEL CESAR SANJUAN CLAZER foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 1º de agosto de 2022, por volta das 14 horas e 28 minutos, na Praça Benedito Franço (altura da rua Neusa Maria Mendes Tonin nº 1320), bairro Serra Verde, nesta cidade e comarca, DANIEL CESAR SANJUAN CLAZER, qualificado a fls. 4, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiro, 12 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 20,3g, e 81 porções de maconha (vegetal que contém THC), com peso bruto aproximado de 83,78g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 2. O processo teve trâmite regular, conforme fls. 103/104, 109, 120/124 e 142. 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos e depoimentos colhidos (fls. 6/8, 9/10, 13/17, 100/102). 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida, em especial pelos depoimentos seguros dos GCMS César Eduardo e Juvenal Estevão. Os servidores públicos contaram que o réu foi surpreendido na praça pública, onde se postou para traficar. Na presença da patrulha, ele esboçou fuga. Foi abordado e submetido à busca pessoal; tinha em seu poder 4 eppendorfs de cocaína (1 na mão e 3 no tênis). Ao ser entrevistado, o réu, admitindo a traficância, informou aos policiais onde escondia o restante de suas drogas. No lugar por ele indicado, sob uma pedra, foram encontrados 8 eppendorfs contendo cocaína (idênticos àqueles apreendidos em poder do denunciado) e 81 porções de maconha 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 84/89 e 90/99), razão pela qual não aplicável a causa de diminuição do parágrafo 4º., do art. 33, da Lei Antitóxicos. Ademais, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena descrita no corpo na denúncia, não obstante não capitulada. De fato, na denúncia oferecida consta que o réu estava praticando o delito em praça pública. Ademais, o guarda ouvido nesta data informou que referida praça é utilizada pela comunidade e inclusive por crianças que estudam ali ao lado, para lazer. Assim, de rigor a aplicação do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM Juíza, segundo denúncia do Ministério Público, o acusado está sendo processado como incurso nas sanções do crime prescrito no art. 33 da lei nº 11.343/06, posto que na data de 01 de agosto de 2022, por volta das 14h30m foi preso em flagrante delito por supostamente trazer consigo e ter em depósito com a finalidade de traficância 3,1g de Cocaína acondicionada em 12 eppendorfs e 68,2g de maconha distribuídos em 81 invólucros. Conforme consta nos autos, guardas civis estavam em patrulhamento de rotina no Bairro Jardim Oriente nesta comarca quando avistaram o denunciado nas proximidades da Praça Benedito Franço e, ao avistar a viatura demonstrou intenso nervosismo, levando então a sua abordagem. Segundo os guardas civis, em revista pessoal foi localizado 04 eppendorfs de cocaína, sendo um em sua mão e 03 em seu tênis e a quantia de R\$ 3,00 (três Reais). Questionado, teria o denunciado indicado aos guardas civis a localização de mais entorpecentes embaixo de uma pedra na referida praça - totalizando 08 eppendorfs de cocaína e 81 invólucros de maconha e, confessado informalmente que estaria traficando naquele local desde as 09hrs da manhã. Conduzido à delegacia, DANIEL esclareceu que é dependente químico e foi até a casa de sua ex-esposa naquele bairro, próximo ao ponto de venda de drogas. Que teria R\$ 33,00 (trinta e três Reais) e tinha gasto quase a totalidade com a compra de 03 porções de cocaína para seu uso. Que estaria caminhando até o ponto de ônibus, quando foi abordado pela guarda municipal, assumindo somente a droga que

estava em seu poder. Instruído o feito, ouvindo as testemunhas de acusação, o Ministério Público se manifestou pela procedência da exordial acusatória. Não obstante, tem-se que a ação não pode ser julgada procedente nos termos propostos pelo nobre Parquet, senão vejamos: PRELIMINARMENTE BUSCA PESSOAL POR QUEM NÃO DETÉM PODER DE POLÍCIA – PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA ILICITAMENTE Conforme constou no auto de prisão em flagrante e foi confirmado em audiência instrutória, na data do fato, a Guarda Civil Municipal estava em patrulhamento, quando visualizou o Acusado em atitude que consideraram “suspeita” e assim decidiram realizar a abordagem. Em revista pessoal, afirmam ter localizado 04 porções de cocaína e a quantia irrisória de R\$ 3,00. Em seguida, teriam obtido a confissão informal do réu acerca da traficância no local, o qual, inclusive teria indicado onde estaria as demais porções de entorpecentes. É dizer, dentro da cadeia de causalidade dos fatos, a atuação dos integrantes da Guarda Municipal foi determinante para a configuração da materialidade e autoria delitivas. O único suporte probatório do Ministério Público quanto à autoria e materialidade são os testemunhos dos guardas municipais, tanto em solo policial como em juízo. A materialidade, sobretudo, somente foi considerada provada graças à busca pessoal no Réu pelos guardas municipais. Sucede que, diferentemente do que acredita a população leiga, guarda municipal não é polícia; conseqüentemente, não tem poder de busca pessoal (art. 244, CPP), sendo irrelevante que um integrante da guarda tenha fundada suspeita de que alguém esteja na posse de drogas. Essa afirmação decorre da interpretação do art. 144, caput e § 8º, da Constituição Federal, o qual não prevê as guardas municipais entre as forças de segurança (listadas na cabeça do artigo), reservando às polícias as atividades de investigação (polícia civil) e de policiamento ostensivo (polícia militar); e facultando a criação, pelos municípios, de guardas municipais “destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei” (§ 8º). A finalidade das guardas municipais, portanto, está muito claramente delimitada pelo constituinte. Note-se que o art. 144, § 8º, da CRFB é norma de eficácia limitada e foi regulamentado pela Lei 13.022/2014, que prevê uma série de competências específicas das guardas municipais, entre elas a de “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social” (art. 5º, inc. IV), bem como de “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário” (art. 5º, inc. XIV). Em nenhum momento, porém, foram os integrantes das guardas autorizados a realizar buscas pessoais, permanecendo tais atividades privativas das polícias. É claro que um guarda municipal pode efetuar uma prisão em flagrante delito, à luz do art. 301 do Código de Processo Penal. Mas o poder que um guarda municipal tem de prender alguém em flagrante é exatamente o mesmo que tem um porteiro, um escrevente judiciário, um artista plástico, um arquiteto, e assim por diante. É o poder que o legislador atribuiu a qualquer do povo, isto é, a qualquer pessoa, independentemente da profissão ou do uniforme utilizado. A situação em exame não revela uma prisão em flagrante passível de ser efetuada por qualquer do povo, já que o imputado foi surpreendido na rua. Um “qualquer do povo”, na dicção do legislador, não teria como vislumbrar o flagrante delito, já que confessadamente não estava ocorrendo ato de comercialização e, se não fosse a revista pessoal a droga que estava em seu poder – 04 eppendorfs de cocaína, não teria sido descoberta. Competiria aos guardas municipais – que não são autoridades nem agentes de autoridade policial –, em último caso, solicitar apoio da Polícia Militar para realizar a abordagem e a revista. A propósito, não se trata de uma simples tese de defesa, mas entendimento compactuado, inclusive, por membros do Ministério Público (aliás, quem propôs a ADI 5156 contra a Lei 13.022/2014 foi o procurador-geral da República). Célebre tornou-se o parecer do procurador de Justiça Luís Antônio Guimarães Marrey na revisão criminal n. 0034551-84.2015.8.26.0000, julgada procedente pelo 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na ocasião, o membro do Parquet assim se manifestou: O exercício do poder de polícia municipal, nas atividades que lhe são próprias, não se confunde com a atividade de polícia judiciária ou de manutenção da ordem pública, deferidas aos Estados e que não podem ser delegadas. Dessa forma é ilegítima a atividade de in-

vestigar e de fazer buscas pessoais ou em veículos por parte de integrantes da Guarda Municipal, em atividade estranha à sua atribuição constitucional. Aceitar-se conclusão contrária significaria admitir que cidadãos comuns devem suportar buscas feitas a esmo por funcionários públicos municipais que não exercem a função policial (...). Se há suspeita de crime, como regra, devem os guardas chamar a polícia e dar as informações pertinentes que permitam a ação policial. Claro que poderão agir quando houver flagrante delito visível, mas o farão na condição de pessoas do povo, como por exemplo um roubo à mão armada que esteja em curso ou em situação de flagrância ou mesmo o tráfico de drogas realizado de maneira explícita. No entanto, ninguém é obrigado a se submeter a revista feita por iniciativa de qualquer pessoa do povo” Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação nº 1501575- 87.2018.8.26.0567. Eis a ementa: Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prova ilícita. Guarda municipal. Competência constitucional. Atividade policial. A atividade de policiamento urbano, seja para repressão dos crimes, seja para sua investigação, é daquelas de maior complexidade que o Estado presta a sua população. Reclama, pois, seleção rigorosa, capacitação e instrução permanentes e, especialmente, acompanhamento atento de uma corregedoria interna e, desde a ótica externa, do próprio Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público. Desde a Independência, em 1822, a nação brasileira vem buscando com muita dificuldade compor e consertar seus órgãos policiais e mesmo seu sistema criminal de justiça sob o império da lei e do Direito. Nada disso, é claro, ocorre com as guardas municipais que, sabidamente, encerram-se no sabor ocasional dos ventos que sopram tão somente no âmbito restrito da localidade. Obviamente, não podem as guardas municipais, portanto, sair mundo afora na suposta investigação criminal propiciada pelas tais denúncias anônimas e, muito menos, ingressar em residências particulares para revistá-las, atividades para as quais as guardas municipais não estão treinadas, não são capacitadas e não têm como ser suficientemente corrigidas. Daí que nossa Constituição Federal reserva às polícias a competência para repressão e investigação de crimes, dispondo tocar às guardas municipais nada mais que o zelo com o patrimônio e serviços do município (artigo 144, parágrafos 4º, 5º e 8º). Deste modo, em vista da obtenção de provas por pessoas não investida constitucional e legalmente de poder de busca pessoal, o caso sub judice reclama a aplicação do art. 157 do Código de Processo Penal, segundo o qual “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais” . E, sem prova de autoria e materialidade obtida licitamente (isto é, em conformidade com os princípios e regras constitucionais e legais), não há crime. Isto posto, REQUER a declaração de NULIDADE das provas, seguida da ABSOLVIÇÃO de DANIEL CESAR SANJUAN CLAZER, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. MERITO Temos duas situações que precisam ser observadas: A primeira é que com o denunciado foi encontrada quantidade de drogas mínimas para o consumo pessoal e a quantia irrisória de R\$ 3,00 (três Reais) totalmente compatível com um usuário de drogas e não com um

traficante, que segundo os guardas civis estaria exercendo o comércio ilegal desde as 09 horas da manhã. A par disso a defesa trouxe aos autos documentos referentes à internações anteriores para tratamento de dependência química. A segunda, é que conforme se colhe da prova dos autos, o denunciado não foi localizado flagrantemente exercendo a venda dos entorpecentes, não sendo crível que teria confessado informalmente o crime em seu próprio prejuízo, até porque, à época dos fatos, estava prestes a começar trabalho formal como prova o exame médico admissional trazido aos autos. É senão o caso de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII). Isso porque os elementos de prova produzidos em juízo são manifestamente insuficientes para atestar a responsabilidade penal do imputado, tudo a evidenciar que não foi superado o standard probatório da presunção de inocência, isto é, não foram produzidos em juízo elementos de prova capazes de apontar para a responsabilidade penal além de qualquer dúvida razoável. Por força do princípio da presunção da inocência – insculpido no art. 5º, LVII, da

Constituição Federal vigente e no art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – deve o órgão acusatório provar a existência de todos os elementos do fato imputado na denúncia para que possa haver condenação penal, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos. Com efeito, para a prolação de uma sentença de condenação, faz-se mister a presença de um conjunto probatório harmonioso e robusto, o que, todavia, não ocorre na hipótese dos autos. Além disso, sendo o detentor do onus probandi, ao Ministério Público incumbe formular seu pleito condenatório a partir dos elementos de prova produzidos em juízo (CPP, art. 156), não podendo amparar o pedido de condenação em elementos de informação colhidos em âmbito inquisitorial (CPP, art. 155), sob pena de violação à garantia do contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV; CADH, art. 8.2.f). Ora, no presente caso, a condenação estaria embasada apenas nas palavras dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante. Sendo assim, é de rigor que seja declarada a absolvição do imputado, tendo em vista a insuficiência dos elementos de prova produzidos em juízo, os quais não permitem concluir pela responsabilidade penal (art. 386, VII, do CPP).

DA DESCLASSIFICAÇÃO A nosso sentir, impõe-se, *prima facie*, a plena absolvição de DANIEL, eis que a prova é obscura e insuficiente para fundamentar o édito condenatório, devendo ser observado o princípio do *in dubio pro reo*. Contudo e subsidiariamente, em vista da ausência de elementos de convicção que comprovem a narcotraficância de forma estreme de dúvidas, é imperiosa a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. As testemunhas de acusação arroladas não podem afirmar, com segurança, a destinação mercantil das drogas, já que sequer houve uma investigação prévia acerca de todos os fatos e, como já afirmado, há também dúvida sobre a suposta confissão extrajudicial, já que não repetida na fase judicial, o que mitiga a verossimilhança das declarações destes agentes públicos. De efeito, a acusação não conseguiu fazer a mínima prova do comércio espúrio. No mesmo sentido, juntamente com a droga, NÃO foi apreendido nenhuma embalagem que indicasse que o apelante se dedicava à mercancia ilícita, tão pouco dinheiro em quantia que indicasse o tráfico de drogas. Assim, sabe-se que o ônus de comprovar que a droga se destinava ao comércio ilícito recai sobre a acusação, a qual não se desincumbiu de tal tarefa, não apresentando nada que comprove com fidedignidade o *fumus commissi delicti*. Em resumo, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, as circunstâncias que envolveram os fatos ora analisados determinam que a droga efetivamente encontrada com DANIEL não era destinada à venda, impondo-se a reclassificação jurídica da conduta atribuída ao denunciado. Uma vez operada a desclassificação, de pronto já se pugna pela ABSOLVIÇÃO, já que a referida incriminação ofende a Constituição Federal, notadamente a isonomia e a dignidade humana, bem como o poder de autodeterminação que cada indivíduo deve ter. Reputado formal e materialmente compatível com a Carta Magna o crime descrito no art. 28, da Lei de Drogas, o que não se espera, alternativamente, requer-se que seja aplicada, tão somente, a pena de ADVERTÊNCIA. Por derradeiro, superado o quanto exposto, caso V.Exa. entenda pela responsabilização criminal do acusado, a defesa apresenta as teses subsidiárias seguintes: No que tange à dosimetria de pena, o dolo é inerente à figura típica e as consequências são normais para casos similares, assim como os motivos para a prática do crime, não justificando uma exasperação na primeira fase. Em relação ao crime de tráfico de drogas, no que se refere à quantidade de entorpecentes, tem-se que não há justificativa para o aumento da pena-base. Isso porque o aumento da pena-base em razão da quantidade de drogas (LC, art. 42), nos delitos de tráfico, exige que a quantidade de drogas seja expressiva. Em relação ao regime de pena, o regime inicial deve ser fixado em estrita observância do art. 33 do Código Penal e, caso se entenda pela fixação de regime mais gravoso, a motivação deve dar-se de modo concreto, conforme se infere das Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedado ao julgador apelar à gravidade em abstrato do delito. É certo, ademais, que, conforme se infere da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso por analogia, a reincidência, por si só, não pode justificar a escolha do regime mais gravoso para o caso. Além disso, em casos de tráfico de drogas, não poderá o regime ser definido com embasamento apenas no disposto no art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos,

tendo em vista que sua inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não obstante o acusado seja reincidente, faz-se possível a fixação o regime inicial semiaberto, aplicando-se ao caso, por analogia, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça".

A seguir, pela MM^a. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

DANIEL CÉSAR SANJUAN CLAZER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 1º de agosto de 2022, por volta das 14 horas e 28 minutos, na Praça Benedito Franço (altura da rua Neusa Maria Mendes Tonin nº 1320), Bairro Serra Verde, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiro, 12 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 20,3g, e 81 porções de maconha, com peso bruto aproximado de 83,78g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado se postou na praça pública para traficar. Nesse local, foi surpreendido por guardas municipais que por ali passavam e o viram esboçar fuga. O réu foi abordado e submetido à busca pessoal. Em poder de DANIEL, os servidores públicos constataram e apreenderam 4 eppendorfs de cocaína (1 na mão e 3 no tênis). Ao ser entrevistado, o acusado, admitindo a traficância, informou aos guardas onde escondia o restante de suas drogas. No lugar por ele indicado, sob uma pedra, foram encontrados 8 eppendorfs contendo cocaína (idênticos àqueles apreendidos em poder do réu) e 81 porções de maconha.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 109) e apresentou defesa preliminar (fls. 120/124), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 125/127).

Designada audiência, foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pela fotografia de fls. 11 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 100/102, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu negou a prática do delito. Disse que estava desempregado e que iria começar a trabalhar na semana posterior aos fatos, com fabricação de fraldas. Afirmou que era viciado em maconha e cocaína. Narrou que, na data dos fatos, foi até a casa de sua ex-mulher, que residia próximo a um ponto de venda de drogas. Disse que tinha R\$ 33,00 e comprou três pinos de cocaína por R\$30,00, pagando R\$10,00 cada um. Aduziu que estava caminhando para o ponto de ônibus quando foi abordado pelos guardas municipais. Asseverou que somente três pinos lhe pertenciam. (fls. 04/05)

Em juízo, voltou a negar a prática do crime. Asseverou que estava na rua de baixo, na casa de sua ex-namorada, pois tentava reatar o relacionamento. Após, foi ao local dos fatos, comprou três pinos de cocaína, R\$ 10,00 cada, e colocou no tênis. Afirmou que ficou nervoso quando viu os guardas porque teve medo de ser preso e iria começar um trabalho no dia 08 daquele mês. Disse que viu onde os guardas acharam a droga, mas não podia indicar a pessoa que lhe vendeu e tinha entrado no bar quando ele foi abordado. Alegou que estava fazendo bicos de pintura quando dos fatos.

A negativa do réu, porém, foi infirmada pela prova produzida.

Com efeito, o guarda municipal César Eduardo narrou que estavam no Jardim Oriente, onde existe uma praça e uma escola municipal, onde costumeiramente fazem patrulhamento e é conhecido como ponto de tráfico. Atestou que avistaram o réu, que, ao notar a viatura, tentou se esconder atrás de um veículo. Então, pararam a viatura e fizeram a abordagem. Na mão do réu, havia um pino de cocaína e, dentro do tênis, havia mais três pinos. Disse que ele também tinha R\$ 3,00. Asseverou que o

r  u lhes falou que estava passando por situa  o dif  cil e, por isso, estava traficando. Aduziu que o r  u lhes indicou um buraco, a aproximadamente quinze metros do local da abordagem, em dois locais distintos, mais por   es de coca  na e 81 de maconha. Informou que n  o conheci ao r  u anteriormente. Esclareceu que a pra  a    utilizada para lazer e tem brinquedos.

No mesmo sentido o depoimento do guarda Juvenal, ouvido a fls. 03.

   de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusa   o serem guardas municipais n  o    o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. N  o estando impedidos, seus depoimentos s  o considerados como o de qualquer testemunha, j   que nenhuma raz  o tinham para falsear a verdade, a n  o serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa,   s penas da lei, na hip  tese de falso testemunho. O depoimento vale n  o pela condi   o do depoente, mas pelo seu conte  do de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, n  o h   raz  o para desprez  -lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusat  ria consistente em depoimentos de guardas municipais    t  o v  lida quanta outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, s  rios e coerentes.

Acrescento que a presun   o de imparcialidade, retid  o e lisura deve ser em favor da autoridade p  blica, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Logo, sequer    razo  vel    razo  vel presumir que guardas civis transitar  am com tamanha quantidade e variedade de drogas para imputar falsamente sua posse ao acusado.

Por fim, n  o houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, j   que, conforme disp  e a lei, qualquer do povo pode efetuar pris  o em flagrante delito (art. 301 do C  digo de Processo Penal). Ali  s, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da pr  tica criminosa, n  o pudessem tomar provid  ncias para fazer cessar a infra   o, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apela   o n   0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado: "Habeas Corpus - Tr  fico de drogas- Pleito de revoga   o da pris  o preventiva - Alega   o de ilegalidade da pris  o realizada por Guardas Municipais. Atua   o dos Guardas Municipais. Ausente ilegalidade - Artigo 301 do CPP - Qualquer pessoa do povo pode, e as Autoridades policiais e seus agentes devem realizar pris  es em flagrante - Crime de Tr  fico de Drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consuma   o protra  da no tempo, permitindo a pris  o em flagrante a qualquer momento. Jurisprud  ncia do C. STJ. No caso em tela, ao que consta, o estado de flagr  ncia se mostrou aparente, de modo que l  cita foi a atua   o dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela seguran  a social. No mais, eventuais irregularidades da pris  o em flagrante restam superadas com a decreta   o da pris  o preventiva do Paciente.

Impossibilidade. Presen  a dos requisitos da cust  dia cautelar - Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, na pr  tica de crime equiparado a hediondo, para o qual    legalmente vedada a liberdade provis  ria, conforme o art. 44, da Lei de Drogas - declara   o de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum - decis  o que n  o vincula esta E. Corte. Aus  ncia de afronta ao princ  pio da presun   o de inoc  ncia - Estado que det  m os meios cab  veis para a manuten   o da ordem p  blica, ainda que em detrimento da liberdade do cidad  o, nos casos em que tal medida se mostrar necess  ria. Inviabilidade da aplica   o de medidas cautelares alternativas, por insufici  ncia, inadequa   o e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2014342-

16.2022.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka;   rg  o Julgador: 8   C  mara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3   Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

N  o bastasse essa orienta   o j   consolidada na jurisprud  ncia, h   que se ressaltar que, conquanto n  o seja essa essencialmente sua fun   o, o guarda municipal est  

autorizado por norma legal expressa a encaminhar à presença da autoridade policial indivíduos presos em flagrante delito, consoante a regra inscrita no artigo 5º, inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

O recente entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a prisão em flagrante perpetrada por guardas municipais é nula sempre que desenvolverem ação pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo e atividade investigativa, por violação de suas atribuições constitucionais, não é aplicável nos casos, como o dos autos, em que os guardas municipais deparam-se com situação de flagrante que não envolve as atribuições próprias das Polícias Civil e Militar.

Nesse sentido: “Não se desconhece a existência de decisões recentes da Sexta Turma desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.977.119/SP, sob a relatoria do eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, que declarou nulas as provas derivadas da prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, considerando que a atividades ostensivas e investigativas são típicas das polícias militares e civis. Na hipótese analisada pelo relator do mencionado apelo nobre, os guardas decidiram abordar o recorrente por desconfiarem da sua conduta, encontrando, na abordagem, certa quantidade de droga em seu poder. A situação descrita no julgado da Sexta Turma, portanto, é distinta daquela tratada nestes autos, em que a abordagem foi precedida de fundadas suspeitas, para além da dúvida razoável, acerca da probabilidade de prática delituosa. Conforme mencionado, os réus foram encontrados carregando sacolas plásticas contendo os objetos furtados por volta das 4h e, tão logo avistaram os guardas municipais, deram início a tentativas de evasão, sendo que um deles dispensou a res furtiva e não foi localizado. Neste caso, portanto, é possível concluir que a situação flagrancial era perceptível de plano, indo além da mera suspeita causada pelo comportamento dos abordados. Todo o contexto fático que antecedeu a ação dos guardas municipais dá suporte à providência por eles tomada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal causado por esse motivo. (STJ, HC 754812, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado: 16/09/2022, publicado: 19/09/2022).

Enfim, o fato de os guardas municipais terem localizado quatro eppendorfs de cocaína na posse do acusado e, nas proximidades do local da abordagem, em lugar por ele indicado, mais oito porções da mesma droga, embaladas de maneira idêntica às encontradas com o réu, além de 81 porções de maconha, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, conduz à certeza quanto a autoria.

Prosseguindo, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito. Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para

angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498). Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo ou tenha em depósito a substância entorpecente.

Por fim, restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, eis que o crime foi praticado nas dependências de uma praça pública. Observo, para constar, que, realmente, a denúncia descreveu a prática do delito de tráfico de drogas com a causa de aumento supracitada, deixando tão-somente de incluir o respectivo dispositivo legal na capitulação do crime.

Logo, é desnecessário qualquer aditamento, prevalecendo o disposto pelo art. 383 do Código de Processo Penal, posto que, como é sabido o acusado se defende da imputação contida no fato descrito na denúncia e não da classificação que lhe deu o requerente.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu ostenta Maus Antecedentes (autos nº 0018305-91.2010 da 1ª Vara Criminal local e nº 0022111-13.2005 da 2ª Vara Criminal local - fls. 84/89), razão pela qual fixo a pena base, acima do valor mínimo legal, em cinco e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

De acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência, mas podem ser consideradas como Maus Antecedentes, nos termos do art. 59 do mesmo código.

Nesse sentido decisão do C. STJ: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas podem ser consideradas como Maus Antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Considerando que o ordenamento jurídico pátrio adota quanto aos Maus Antecedentes o sistema da perpetuidade, e não da temporariedade, como no caso da reincidência, é de se manter o entendimento pacificado por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o prazo depurador, as condenações anteriores podem ser consideradas como Maus Antecedentes. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp nº 1.604.407/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12.08.2016).

E o STF, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Na segunda fase de fixação da pena, está presente a agravante da reincidência (autos nº 0001342-05.2017 da 2ª Vara Criminal local - fls. 84/89), razão pela qual aumento a pena em um sexto, resultando seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase de fixação da pena, aplico o aumento de um sexto, com fundamento no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, resultando sete anos, onze meses e oito dias de reclusão e setecentos e noventa e três dias-multa. Não há causas de redução da pena.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em decorrência da reincidência e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a

hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o réu DANIEL CÉSAR SANJUAN CLAZER, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão e setecentos e noventa e três dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra preso e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Desde já sai o(a) Defensor(a) intimado do prazo para apresentação das razões de apelação, independentemente de nova intimação, uma vez que trata-se de processo digital e o recurso foi recebido neste momento.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 11/12/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de

Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]